

刑法
No.390

共通問題 H28-8

(配点: 2)

月 日

月 日

わいせつの罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 甲は、人通りの多い駅構内において、自己の性器を露出させたが、実際には、それに気付いた人はいなかった。この場合、甲には公然わいせつ罪は成立しない。
2. 甲は、日本国外で販売する目的で、日本国内において、わいせつな映像が録画されたDVDを所持した。この場合、甲にはわいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。
3. 甲は、友人乙からの土産に対するお礼として、わいせつな映像が録画されたDVD1枚を乙にプレゼントした。この場合、甲にはわいせつ物頒布罪は成立しない。
4. 甲は、不特定多数の通行人を勧誘して5名の客を集めた上、自宅であるマンションの一室において、外部との出入りを完全に遮断した状態で、わいせつな映像が録画されたDVDを再生し、その5名の客に有料で見せた。この場合、甲にはわいせつ物公然陳列罪が成立する。
5. 甲は、海水浴場において、不特定多数の者の面前で、乙女の衣服を全てはぎ取るなどして強いてわいせつな行為をした。この場合、甲には、不同意わいせつ罪が成立するのみならず、公然わいせつ罪も成立する。(改)

No390

わいせつの罪

正答率

89%

共通H28-8

正解

1

1 誤っている

東京高判昭32.10.1。174条における「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいい（最決昭32.5.22）、現実には不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識可能性があれば足りる。裁判例は、本記述と同様の事案において、不特定多数の人が通行する可能性のある場所でわいせつな行為に及んだ場合には、たとえ現実にはその際に通行人が全くいなかったとしても、公然性に欠けることはないとしている。本記述において、甲は、人通りの多い駅構内において、自己の性器を露出させており、不特定又は多数の人が認識する可能性がある以上、「公然」に当たり、実際にはそれに気付いた人はいなかったとしても、公然わいせつ罪が成立する。

2 正しい

最判昭52.12.22は、本記述と同様の事案で、175条2項における「『販売の目的』〔注：現「有償で頒布する目的」〕とは日本国内において販売する目的をいうものであり、したがって、猥せつの図画等を日本国内で所持していても日本国外で販売する目的であったにすぎない場合には同条後段〔注：現175条2項〕の罪は成立しないと解するのが相当である」としている。その理由として、判例は、「刑法175条の規定は、わが国における健全な性風俗を維持するため、日本国内において猥せつの文書、図画などが頒布、販売され、又は公然と陳列されることを禁じようとする趣旨に出たものである」ということを挙げている。本記述において、甲は、日本国外で販売する目的で、わいせつな映像が録画されたDVDを所持しているため、わいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。

3 正しい

大判大15.3.5は、175条1項における「頒布」とは、不特定又は多数の人に対して交付・譲渡することをいうとしている。本記述において、甲は、わいせつな映像が録画されたDVD1枚を乙にプレゼントしているにとどまり、この行為は不特定又は多数の人に対して交付・譲渡したことにならないから、「頒布」に当たらず、わいせつ物頒布罪は成立しない。

4 正しい

最決昭33.9.5は、本記述と同様の事案で、わいせつ物公然陳列罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、175条1項の「公然」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいうところ、特定・少数の者にわいせつな行為を見せた場合でも、それが不特定・多数人を勧誘した結果であれば、なお公然性を肯定し得るということを挙げている。本記述において、甲は、5名の客をマンションの一室に集め、外部との出入りを完全に遮断した状態で、わいせつDVDを再生しているため、特定・少数の者に対してわいせつDVDを見せていることになる。しかし、甲は、不特定多数の通行人を勧誘した結果として上記5名をマンションの一室に集めているため、公然性を満たしている。よって、甲にはわいせつ物公然陳列罪が成立する。

5 正しい

大判明43.11.17は、不同意わいせつ行為を公然と行った場合につき、強制わいせつ罪（現：不同意わいせつ罪）と公然わいせつ罪が成立し、両罪は観念的競合となるとする。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、両罪の保護法益が異なることを挙げている。本記述において、甲は、乙女の衣服をすべてはぎ取るなどして強いてわいせつな行為をしているので、不同意わいせつ罪が成立する。また、海水浴場において、不特定多数者の前で行っているため、公然わいせつ罪も成立し、両罪は観念的競合となる。